

1501695-97.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... encontrado era proveniente do trafico de drogas. Diante do cenário, apresentaram o indiciado nesta unidade para as providências legais de Polícia Judiciária. Por fim informa que a Escola Professora Lenita Correa , fica há 120 metros do local onde o indiciado realizava o trafico de drogas". Em juízo afirmou: que estava em patrulhamento e receberam informação por denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501695-97.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501695-97.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2187608/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 18994557 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2223/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA qualificado às fls. 18 está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal, porque segundo narra a denúncia de fls. 01/02, no dia 12 de julho de 2021, por volta de 08h30, em ocasião de calamidade pública¹, na Rua Paulo Brossard, altura do numeral 2100, Jardim Vassouras I, Francisco Morato/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, dentro de uma mochila, 8 (oito) porções da droga conhecida como maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 36g (trinta e seis gramas), tudo conforme depoimentos prestados em sede policial, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória de substância entorpecente, croqui do

local dos fatos e laudo de exame químico-toxicológico.

A decisão de fls. 67/70 converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A decisão de fls. 103/104 adotou o rito ordinário e determinou a citação do réu.

O réu foi citado (fls. 130) e apresentou defesa prévia às fls. 136/137).

A decisão de fls. 154/155 ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e debates que foi realizada por videoconferência em razão da Pandemia da Covid-19.

Em audiência de instrução e julgamento o réu foi interrogado, bem como ouvidas duas testemunhas de acusação.

O Ministério Público, em alegações finais pediu a condenação nos termos da denúncia. Quanto a dosimetria pede que se considerem as duas reincidências na segunda fase, vedando-se a aplicação do § 4 do artigo 33 da Lei de drogas. Pede regime fechado. Com relação a alegação do réu de que sofreu agressão física durante a abordagem policial, nada requer, justificando que se esta tivesse ocorrido seria compatível com dinâmica para contenção do réu, no entanto, o exame de corpo de delito nada constou.

A Defesa de apresentou alegações finais, pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o artigo 28, vez que o acusado era apenas usuário. Em caso de condenação, pleiteia a fixação da pena nos patamares mínimos legais, levando em consideração a natureza e quantidade de drogas apreendida. Requer ainda o afastamento da agravante do artigo 61, II, "j", vez que o agente não prevaleceu da calamidade pública para praticar o crime.

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga e dinheiro (fls. 12); laudo de constatação da droga (fls. 25/26); laudo pericial químico toxicológico (fls. 90/92); croqui do local dos fatos (fls. 39/40); folha de antecedentes (fls. 120/125) e certidão de distribuições criminais (fls. 116/118).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem assim, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame de substâncias psicoativas, auto de apreensão da droga/dinheiro e guia de depósito de dinheiro apreendido.

A testemunha DEBORA MARIA GONÇALVES foi ouvida na fase policial (fls. 05) e afirmou: "efetuei patrulhamento nas imediações da Rua Paulo Brossard, Jd.

Vassouras I, nesta urbe, na companhia do Policial Jefferson, no momento em que receberam denúncia de um popular não identificado o qual afirmou um indivíduo ao visualizar a viatura policial adentrou rapidamente no ônibus

Terminal/Jardim Esperança com um mochila aparentemente tentando se esconder dos militares, deste modo, efetuei acompanhamento ao referido coletivo, tendo dado sinal de parada, quando embarcaram no ônibus, o indiciado WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA ao visualizar a guarnição, abandonou a mochila que trazia consigo no banco do ônibus e desceu rapidamente pela porta de trás aproveitando o momento em que descia um passageiro não identificado. Por conseguinte, na companhia da Policial Debora efetuei abordagem ao indiciado WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA, e mediante busca localizaram dois telefones celulares, sendo que na mochila dispensada pelo indiciado, localizaram 08 (oito) porções de maconha/raxixe e a quantia de R\$ 240,25 (duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavo) em notas diversas. Deste modo, questionaram o indiciado WELLINGTON, o qual afirmou passou a noite comercializando entorpecentes do tipo maconha/raxixe próximo ao Terminal de Ônibus, e que estava retornando para casa, por isso estava com pouca quantidade de drogas, pois havia vendido e o dinheiro encontrado era proveniente do tráfico de drogas.

Diante do cenário, apresentaram o indiciado nesta unidade para as providências legais de Polícia Judiciária. Por fim informa que a Escola Professora Lenita Correa, fica há 120 metros do local onde o indiciado realizava o tráfico de drogas". Em juízo afirmou: que estava em patrulhamento e receberam informação por denúncia anônima que o indivíduo estaria dentro dum ônibus (não se lembra se falaram o delito que ele estaria praticando), tendo os policiais se dirigido até o ônibus,

feito acompanhamento, parando-o, sendo que, na abordagem o réu empurrou um passageiro que acabou caindo em cima do parceiro de farda, na saída do ônibus; que foi possível deter o réu pois havia mais uma viatura em apoio; que consultando o IRGD dele constou que ele era procurado; que numa mochila havia droga e dinheiro; que num primeiro momento quando o réu viu a viatura ele desceu no primeiro ponto seguinte; que o réu estava com a mochila quando foi detido; que conhecia o réu por rolo de moto, ter dado fuga da viatura em que estava a depoente, mas não conseguiu aborda-lo; que Rua Paulo Brossard 2100 é o terminal (próximo da rua das Hortências/marginal - é distante, não sabendo precisar mas deve ter mais de 1 km; que o ônibus já tinha saído do terminal; que no ônibus o réu estava com a mochila e ao descer estava sem, razão pela qual a depoente se dirigiu ao assento que o réu foi visualizado por ela sentado e localizou a mochila que tinha droga e dinheiro; que não se recorda da versão dada pelo réu.

A testemunha JEFFERSON JOSÉ DA SILVA também ouvida na fase de inquérito (fls. 06) afirmou: "que na companhia da Policial Debora, receberam denuncia de um popular não identificado o qual afirmou um individuo ao visualizar a viatura policial adentrou rapidamente no ônibus Terminal/Jardim Esperança com um mochila aparentemente tentando se esconder dos militares, deste modo, efetuou acompanhamento ao referido coletivo, tendo dado sinal de parada, quando embarcaram no ônibus, o indiciado WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA ao visualizar a guarnição, abandonou a mochila que trazia consigo no banco do ônibus e desceu rapidamente pela porta de trás aproveitando o momento em que descia um passageiro não identificado. Por conseguinte, na companhia da Policial Debora efetuaram abordagem ao indiciado WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA, e mediante busca localizaram dois telefones celulares, sendo que na mochila dispensada pelo indiciado, localizaram 08 (oito) porções de maconha/raxixe e a quantia de R\$ 240,25(duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavo) em notas diversas. Deste modo, questionaram o indiciado WELLINGTON, o qual afirmou passou a noite comercializando entorpecentes do tipo maconha/raxixe próximo ao Terminal de Ônibus, e que estava retornando para casa, por isso estava com pouca quantidade de drogas, pois havia vendido e o dinheiro encontrado era proveniente do trafico de drogas. Diante dos fatos apresentou a ocorrência nesta Unidade Policial. Por fim informa que a Escola Professora Lenita Correa , fica há 120 metros do local onde o indiciado realizava o trafico de drogas". Em juízo afirmou: que receberam ligação anônima de que um indivíduo estava provavelmente foragido; que na av Paulo Brossard em sentido Boa Esperança, visualizaram o réu dentro do coletivo, seguindo-o, até chegar na altura da ocorrência onde o ônibus parou, tendo a parceira ido até a frente do ônibus, que o réu acabou pulando do ônibus pela porta dos fundos, tendo inclusive derrubado um passageiro; que o pessoal do ônibus indicou que o réu deixou mochila no ônibus, tendo checado e localizada mochila com maconha; que o réu confessou que estava trabalhando numa biqueira perto da estação do trem; que o réu falou que morava no Jd Esperança e estava retornando pois tinha passado a noite fora; que também havia muita nota trocada de R\$ 2,00, mas o depoente não se recorda se o réu admitiu que o dinheiro era proveniente do tráfico; que o réu já foi preso outras vezes, estando foragido; Que na fuga no dia dos fatos o réu tentou subir um muro, mas como era muito alto, acabou esbarrando nuns carros que estavam estacionados, tendo caído, mas foi algemado na sequencia; que não consegue informar se foi levado para atendimento médico;

O réu WELLINTON ALEXANDRE DA SILVA foi interrogado na fase de inquérito (fls. 07), oportunidade que afirmou: "que não foi agredido porém durante o algemamento tentou fugir caiu ao solo ferindo o interior da boca. Que passou a noite vendendo drogas, do tipo maconha, ao terminal de ônibus e agora pela manhã estava indo embora quando ao descer do ônibus foi abordado por Policiais Militares. Que a mochila que foi encontrado no ônibus é de sua propriedade. Que é procurado pela justiça pois saiu de "saidinha de pascoa" em 2019 pelo crime de roubo e receptação. Informa ainda que trabalha dia sim dia não, no período noturno, ganhando R\$ 300,00 por noite. Que o dinheiro que estava consigo foi o resultado das vendas da noite". Em juízo afirmou: que trabalha com seu sogro e na oportunidade tinha pegado vale, no valor de R\$ 285,00, tendo passado na biqueira e pegado 8 parangas para fumar,

pagando R\$ 5,00 cada e tendo pagado, cerca de R\$ 2,50/3,00, sobrando o troco; que dinheiro e droga estavam na mochila; que em nenhum momento confessou tráfico para o policial, mas deu exatamente a versão de agora; que confirma que tentou fugir no momento da abordagem policial, pois estava com a mulher gestante e queria ver a filha nascer, especialmente porque sabia da sua condição de foragido; que já conhecia Débora de outra ocorrência, mas o policial Jeferson não; que o dinheiro foi dado pelo sogro foi no mesmo dia da ocorrência; que perguntado se o réu não achava importante chamar o sogro para ser ouvido na delegacia sobre a entrega de dinheiro, falou que não tem contato com ele e sua mãe não sabe onde ele mora; que na delegacia não pegaram o depoimento do réu, tendo pedido apenas que ele assinasse sem ler; que nunca foi processado por tráfico; que faz uso apenas de maconha desde os 10 anos de idade, sendo que, está com 23 anos de idade; que utilizava maconha todos os dias no momento em que acordava; que machucou o lado interno da boca na ocorrência, pois na fuga tentou pular o muro, não conseguiu subir, foi puxado pelos policiais no rodo e pisado na sua cabeça.

Primeiramente cumpre-nos analisar sobre eventual nulidade no interrogatório do réu. Oportuno mencionar que os inquéritos policiais atuais são digitais, sendo certo que a ausência de assinaturas nos termos de declarações e autos de reconhecimento não macula o auto de prisão em flagrante, uma vez que as peças contêm a assinatura digital da Autoridade Policial, que confere autenticidade aos documentos, não se olvidando ainda de que os funcionários públicos gozam de fé pública.

Afirmou o réu que não confessou na fase policial que havia praticado traficância durante toda noite, que não leu seu interrogatório prestado em sede administrativa, tendo apenas a autoridade policial pedido que ele assinasse sem ler. Por outro lado, as alegações finais da defesa sugerem nulidade do interrogatório do réu, por ausência de sua assinatura. Ora, como afirma o réu que "assinou sem ler" o termo de inquérito se a sua assinatura sequer foi exigida naquela ocasião? Não há qualquer indício, mínimo que seja, que confira suporte à versão ofertada em autodefesa. Ademais, afirmou o réu em juízo que estudou até o segundo colegial o que demonstra que o réu sabia ler na ocasião dos fatos, e que portanto concordou com as informações lançadas em seu interrogatório na fase policial.

Sustentou a defesa em alegações finais, também em dissonância com a afirmação do réu em Juízo, que: "em que pese constar nos autos um termo de interrogatório onde o réu afirma ter comercializado drogas durante a madrugada, verifica-se que o documento juntado as fls. 07 não possui a assinatura do denunciado, o que, num primeiro momento, coloca em dúvida se o teor do termo de fato corresponde com o que fora dito pelo Réu".

Afinal, o réu assinou sem ler ou não assinou o termo de interrogatório na fase policial? De fato, não assinou. Como já esclarecido anteriormente, os inquéritos policiais atuais são digitais e que prescindem das assinaturas das partes envolvidas na ocorrência, sendo apenas necessário a assinatura da autoridade policial. Nesta linha, importante novamente ressaltar que as peças do inquérito digital contêm a assinatura digital da Autoridade Policial (nota de rodapé de fls. 07), que confere autenticidade a todas peças, inclusive do interrogatório do réu, não se olvidando ainda de que os funcionários públicos gozam de fé pública.

Ademais, os elementos ali colhidos se destinam a simplesmente dar suporte a eventual ação penal e não servem, por si só, para embasar a condenação (art. 155, do Código de Processo Penal), de sorte que a assinatura de documentos não poderia ser o único elemento a fundamentá-la.

Desta feita, não há que se falar em nulidade do interrogatório do réu na fase de inquérito. Também neste sentido:

HABEAS CORPUS - Tráfico Ilícito de Drogas - Inquérito policial - Peça meramente informativa - Preliminarmente - Nulidade do Flagrante - Ausência de assinatura do paciente no termo de interrogatório e nota de culpa produzidos durante a fase policial - NÃO VERIFICADO - Assinatura digital pela autoridade policial que possui fé pública para a prática dos atos inerentes à investigação - Vícios do inquérito que, ademais, não viciam a ação penal - Prejuízo não demonstrado. Da mesma forma, não se vislumbra qualquer ofensa ao preceituado no art. 304, § 3º, do CPP. Por fim,

também não se verifica a ilegalidade do auto de prisão em flagrante no tocante à confissão informal do paciente aos policiais, quando de sua abordagem, que seria ato nulo porque não foi precedido da advertência acerca do seu direito constitucional ao silêncio - NÃO VERIFICADO - O direito ao silêncio, nos termos do artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, é garantido ao preso, ao indiciado e ao acusado na persecução penal. Entretanto, não se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante de algum investigado. No mérito, insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz ainda, que estão ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da prisão cautelar - IMPOSSIBILIDADE - Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a amparar a persecução penal. A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na grande quantidade de droga apreendida e circunstâncias do fato, indicando a periculosidade concreta do paciente - Periculum Libertatis - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21940136720208260000 SP 2194013-67.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 15/09/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/09/2020)

Habeas corpus - Inquérito policial - Peça meramente informativa - Alegação de ausência de assinaturas nos documentos produzidos durante a fase policial - Assinatura digital pela autoridade policial que possui fé pública para a prática dos atos inerentes à investigação - Vícios do inquérito que, ademais, não viciam a ação penal - Prejuízo não demonstrado - Nulidade - Inocorrência - Constrangimento ilegal - Inexistência - Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 20035385720208260000 SP 2003538-57.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 19/02/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2020)

Por outro lado, verifico que as testemunhas de acusação apresentaram um depoimento coeso na fase policial, o qual foi reafirmado judicialmente. Afirmaram na fase administrativa que: "efetuava patrulhamento nas imediações da Rua Paulo Brossard, Jd. Vassouras I, nesta urbe, na companhia do Policial Jefferson, no momento em que receberam denúncia de um popular não identificado o qual afirmou um indivíduo ao visualizar a viatura policial adentrou rapidamente no ônibus

Terminal/Jardim Esperança com um mochila aparentemente tentando se esconder dos militares, deste modo, efetuou acompanhamento ao referido coletivo, tendo dado sinal de parada, quando embarcaram no ônibus, o indiciado WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA ao visualizar a guarnição, abandonou a mochila que trazia consigo no banco do ônibus e desceu rapidamente pela porta de trás aproveitando o momento em que descia um passageiro não identificado. Por conseguinte, na companhia da Policial Debora efetuaram abordagem ao indiciado WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA, e mediante busca localizaram dois telefones celulares, sendo que na mochila dispensada pelo indiciado, localizaram 08 (oito) porções de maconha/raxixe e a quantia de R\$ 240,25 (duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavo) em notas diversas. Deste modo, questionaram o indiciado WELLINGTON, o qual afirmou passou a noite comercializando entorpecentes do tipo maconha/raxixe próximo ao Terminal de Ônibus, e que estava retornando para casa, por isso estava com pouca quantidade de drogas, pois havia vendido e o dinheiro encontrado era proveniente do trafico de drogas. Em juízo a testemunha DEBORA MARIA GONÇALVES afirmou novamente que: "que estava em patrulhamento e receberam informação por denúncia anônima que o indivíduo estaria dentro dum ônibus (não se lembra se falaram o delito que ele estaria praticando), tendo os policiais se dirigido até o ônibus, feito acompanhamento, parando-o, sendo que, na abordagem o réu empurrou um passageiro que acabou caindo em cima do parceiro de farda, na saída do ônibus; que foi possível deter o réu pois havia mais uma viatura em apoio; que numa mochila havia droga e dinheiro; ; que no ônibus o réu estava com a mochila e ao descer estava sem, razão pela qual a depoente se dirigiu ao assento que o réu foi visualizado por ela sentado, e localizou a mochila

que tinha droga e dinheiro". A testemunha JEFFERSON JOSÉ DA SILVA afirmou em juízo: "que receberam ligação anônima de que um indivíduo estava provavelmente foragido; que na av Paulo Brossard em sentido Boa Esperança, visualizaram o réu dentro do coletivo, seguindo-o, até chegar na altura da ocorrência onde o ônibus parou, tendo a parceira ido até a frente do ônibus, que o réu acabou pulando do ônibus pela porta dos fundos, tendo inclusive derrubado um passageiro; que o pessoal do ônibus indicou que o réu deixou mochila no ônibus, tendo checado e localizada mochila com maconha; que o réu confessou que estava trabalhando numa biqueira perto da estação do trem.

Nesta esteira, observo que o testemunho dos policiais foram coesos e encontram respaldo nas demais provas amealhadas aos autos. É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Há de se levar em conta que o acusado afirmou que não conhecia o policial Jefferson, mas que conhecia a policial Débora de outra ocorrência, versão esta que foi corroborada com a própria testemunha que afirmou: "que conhecia o réu por rolo de moto", afirmações estas que, porém, não desabonam os depoimentos apresentados pelas testemunhas, tanto na fase judicial como em Juízo. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" . (TJMG, RT 604/407).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos prestados pelos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos. Ademais, o réu afirmou na fase policial que: "passou a noite vendendo drogas, do tipo maconha, ao terminal de ônibus e agora pela manhã estava indo embora quando ao descer do ônibus foi abordado por Policiais Militares. Que a mochila que foi encontrado no ônibus é de sua propriedade. Que é procurado pela justiça pois saiu de "saidinha de pascoa" em 2019 pelo crime de roubo e receptação. Informa ainda que trabalha dia sim dia não,

no período noturno, ganhando R\$ 300,00 por noite. Que o dinheiro que estava consigo foi o resultado das vendas da noite".

Como se vê, a confissão realizadas perante a autoridade policial revelou-se em consonância com as demais provas trazidas e colhidas sob o crivo do contraditório, tendo a jurisprudência se orientado no sentido de que, em regra, a prova constante do inquérito policial não deve ser desprezada.

As confissões extrajudiciais, obtidas regularmente e ajustados seus termos com as demais circunstâncias ocorridas no caso, têm alto valor probante e podem ser aceitas se não elididas na fase judicial, como na hipótese. A confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que ela contém e não pelo local onde é prestada.

Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pelas palavras das testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação judicial dos réus, sem qualquer explicação plausível para a versão ofertada em sede policial e a mudança para outra totalmente inverossímil.

Inegável, assim, o valor probatório decorrente do entrosamento dos vários elementos de convicção (v. Código Processo Penal, arts. 6º, inc. V, 199, 197 e 157, combinados; JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Forense, 1961, vol. II, ns. 483 e 484, págs. 329-30; ADALBERTO JOSÉ Q. T. CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, cap. XVIII, 4, pág., 195; RTJ, 81/337, 88/371, 90/750, 93/131, 95/563 e 143/306; RT, 421/267, 426/439, 507/417, 547/396, 549/358-390, 553/423, 569/289, 574/384, 578/374-402, 631/331, 675/395, 681/385, 689/439, 714/401, 715/481, 717/417, 724/712, 725/667 e 729/583; RJDTACrSP, 15/48, 19/75, 21/137-266 e 22/276; RJTJESP, 82/401 e 84/359; JTACrSP, 53/251, 56/197, 57/382, 61/242, 63/46, 64/26-293-294 E 66/263).

Nesse contexto, tem-se que deve prevalecer a versão apresentada pelo acusado na fase administrativa, valendo destacar que nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais:

"A confissão extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, já que a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestado, mas pela força de convencimento que nela se contém" (TJSP, RT 668/275);

"PROVA - Confissão extrajudicial - Valor - Prevalência desta sobre a retratação judicial - Inexistência de fatos que possam implicar no reconhecimento de falsa confissão na polícia - Depoimento em consonância com o restante do conjunto probatório - Condenação Possibilidade - Apelo parcialmente provido" (TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1.097.136-3/8, Relator Pinheiro Franco, j. 30/08/07).

Assevero não ser crível a versão do réu de que trabalha com seu sogro e que na oportunidade tinha pegado vale no valor de R\$ 285,00, tendo passado na biqueira e pegado 8 "parangas" para fumar, pagando R\$ 5,00 cada e tendo pagado, cerca de R\$ 2,50/3,00, sobrando o troco; que dinheiro e droga estavam na mochila. O réu não trouxe aos autos nenhuma prova documental ou testemunhal que comprovasse o alegado. Apenas afirmou em juízo: "que o dinheiro foi dado pelo sogro foi no mesmo dia da ocorrência; que perguntado se o réu não achava importante chamar o sogro para ser ouvido na delegacia sobre a entrega de dinheiro, falou que não tem contato com ele e sua mãe não sabe onde ele mora". Do exposto as afirmações que trabalhava para o sogro que lhe deu um vale naquela oportunidade, e na mesma oportunidade também afirmar que "não sabe onde ele mora", revelam-se inverossímeis, não sendo, portanto, aptas a afastar o decreto condenatório.

Neste ponto, não demonstrou a defesa, como seria de rigor, que de fato o réu portava drogas que acabara de adquirir, uma vez afirmar ser usuário de maconha, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, ao passo que a prova indiciária do crime foi realizada, enquanto aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se produziu (artigo 156, do Código de Processo Penal). Acrescento ainda que, "No processo penal, em virtude da vigência dos princípios de investigação oficial e da verdade material, o julgador deve chegar à verdade dos fatos tal como ocorreram historicamente, e não tal como querem as partes que apareçam realizados'" (Magalhães Noronha, Curso de Direito Processual

Penal, Ed. Saraiva, 1974, p. 85) .

Fernando da Costa Tourinho Filho, analisando o art. 156 do CPP, comenta: "A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador afirma que M. furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque, enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente inocente. Se este alega que a pretensa 'res furtiva' era sua, compete-lhe a prova. Ônus da prova nada mais é senão o encargo, que compete à parte que fizer a alegação, de demonstrá-la. Provar não é obrigação; é simples encargo. Se a parte que fizer a alegação não prová-la, sofrerá amarga decepção. Cabe à acusação demonstrar, e isto de modo geral, a materialidade e a autoria. Já à defesa incumbe provar eventual alegação de exclusão da antijuridicidade do fato típico (causas excludentes da criminalidade, excludentes da antijuridicidade, causas justificativas ou descriminantes) ou excludentes de culpabilidade. Se o réu invoca em alibi, o ônus da prova é seu. Se argui legítima defesa, estado de necessidade, etc., o 'onus probandi' é inteiramente seu... Se alegar e não provar, a decepção também será sua. (...) Em função do princípio da presunção universal de inocência, 'o encargo de destruí-la recai sobre os acusadores e não existe nunca ônus do acusado sobre a prova da sua inocência' (F. Gomes de Liaño, La Prueba en el Proceso Penal, Oviedo, 1991, p. 22)" (Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, Ed. Saraiva, 1999, pp. 356/357). Também neste sentido:

"FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. QUALIFICADORA QUE ESTARIA COMPROVADA NOS AUTOS. RÉU QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A CONFIRMAREM SUAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO

AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.MÁCULA. De acordo com o artigo 159 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem fizer". 2. Em virtude do princípio da presunção de inocência, cabe à acusação, via de regra, provar os fatos descritos na denúncia ou queixa, podendo o réu, por sua vez, produzir os elementos de convicção necessários à comprovação de suas alegações. 3. No caso dos autos, não se atribuiu à defesa o encargo de comprovar a qualificadora do rompimento do obstáculo, que estaria evidenciada por vários elementos de convicção coletados, tendo-se apenas salientado que ao réu competia produzir provas que sustentassem a sua versão, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do acórdão em razão da inversão do ônus da prova para a condenação". (HC 328.021/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 15/09/2015).

Assevero ainda que a versão do réu apresentada em juízo que sofreu agressão física durante a abordagem policial também não merece respaldo, uma vez que o próprio réu afirmou naquela oportunidade: tentou fugir no momento da abordagem policial, pois estava com a mulher gestante e queria ver a filha nascer, especialmente porque sabia da sua condição de foragido". Afirmou ainda que: "que machucou o lado interno da boca na ocorrência, pois na fuga tentou pular o muro, não conseguiu subir". Afirmou, por fim, na fase policial que: "que não foi agredido porém durante o algemamento tentou fugir caiu ao solo ferindo o interior da boca", versões estas que corroboram com o exame pericial juntado às fls. 93/94.

Portanto, demonstrado que o réu trazia a droga, o seu destino tem que ser analisado pelos demais elementos que cercam a questão.

No caso dos autos, a droga apreendida (maconha), a forma como estava dividida e embalada para pronta distribuição, o dinheiro, os antecedentes infracionais e criminais do réu e, ainda, o depoimento das testemunhas, e confissão extrajudicial, levam à certeza de que o réu trazia drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "possuir", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

A propósito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 - 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 03.09.09 - Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542).

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP - Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 - 14ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

Ressalta-se que no caso dos autos, as circunstâncias que cercaram os fatos, demonstram a traficância e não autorizam a eventual classificação da conduta como simples consumo pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

Resta, portanto, afastada a hipótese de desclassificação para o delito de uso.

Nesse sentido:

"DESCCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE USO - Inadmissibilidade - Quantidade e diversidade de entorpecentes - Conjunto probatório suficiente para ensejar o decreto condenatório - Inexistência de prova segura que autorizasse decretar nova definição jurídica da conduta." (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 990.08.080898-2, Des. Rel. Leonel Costa, j. 28/04/09).

E o fato de, eventualmente, o acusado afirmar que é usuário de droga, o que não se vislumbra na hipótese, não é suficiente para a desclassificação do delito de tráfico, sendo, repita-se à exaustão, a condenação de rigor: Cita-se como reforço de fundamentação:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP 101/498).

Desse modo, bem demonstrada se encontra a responsabilidade penal do réu pelo delito apontado na inicial, sendo de rigor a sua condenação.

Em suma, demonstrado que o réu trazia consigo dentro de uma mochila 8 porções de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, com massa bruta total de aproximadamente 36g (trinta e seis gramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de comercialização.

Passo a dosimetria da pena.

1.A) Pena-base: 5 anos e 10 meses de reclusão e, 583 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e conseqüências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, conforme certificam os documentos de fls. 116/118 e 120/125 (processo 0001802-23.2016.8.26.0115 que tramitou perante 2ª Vara da Comarca de Campo Limpo e processo 0000651-67.2016.8.26.0197 que tramitou perante este Juízo da 2ª Vara da Comarca de Francisco Morato), o que autoriza a exasperação da pena-base em 1/5. Assim considerando, resulta numa pena de 1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias multa.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o réu confessou o delito na fase de

inquérito, porém praticou o delito durante a pandemia da Covid-19 (artigo 61, II, "j"). Assim, presentes atenuante e agravante, compenso-as. Verifico ainda que o réu é reincidente em crime doloso (processo 0002357-40.2016.8.26.0115, que tramitou perante 2ª Vara da Comarca de Campo Limpo) razão pela qual exaspero a pena em 1/6, resultando em 7 meses de reclusão e 700 dias multa.

Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/03/2021).

C) Causas de aumento e de diminuição: Não aplicável ao caso a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343, razão pela qual torno definitiva a pena de 7 meses de reclusão e 700 dias multa. de reclusão, e dias-multa. unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Anoto que reconheço a reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria da pena, bem como para afastar a incidência da diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, curvando-me à jurisprudência majoritária dos Tribunais. Nesse sentido: RHC 121598 / SP - SÃO PAULO; RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 21/10/2014; Órgão Julgador: Primeira Turma. Ainda, podemos citar: HC 363761/ TO HABEAS CORPUS 2016/0191886-0; Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181); Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento 10/11/2016; Data da Publicação/Fonte DJe 18/11/2016.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo que na espécie é de 1/30 do salário-mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

D) LIBERDADE: O acusado não faz jus ao apelo em liberdade em razão da prisão em flagrante, bem como, por ter permanecido preso durante a instrução pela decretação da sua prisão preventiva (fls. 67/70). Não faria sentido agora, com sentença condenatória, ficar solto, se a situação que motivou a sua prisão cautelar permanece inalterada (HC 867.918-3/3, 5ª Câmara Crim., Rel. Sérgio Rui, 6-10-2005, v.u., Voto n. 4069; HC 517.60/0-00, São Paulo, 13ª Câmara Crim., Rel. Lopes da Silva, 9-6-2005, v.u.; TJSP, RT 836/548).

E) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: O tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas. Além disso, cuida-se de delito equiparado aos hediondos, razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime fechado, como expressamente previsto no artigo 2º, II, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07. Acrescento ainda os fundamentos da dosimetria da pena.

F) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: Não estão presentes os requisitos do artigo 44, III, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.
G) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não estão presentes os requisitos do artigo 77, II, do Código Penal, conforme exposto na dosimetria da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu WELLINTON ALEXANDRE DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. Artigo 61, II, "j" do Código Penal , fixando-a em reclusão de 7 anos e 700 dias-multa, unidade igual a 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida nos termos da fundamentação.

Expeça-se mandado de prisão.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, ficando, nos termos do artigo 63 da Lei 11.340 decretada a perda da importância de R\$ **em favor da União, que deverá ser revertida diretamente ao Funad.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Condeno, outrossim, o acusado ao pagamento de taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

Francisco Morato, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA